

<제6편 상소심절차.제16장 항고.제2절 항고의 절차>

I. 항고의 제기

1. 항고장의 제출

- 항고를 제기하고자 하는 자는 항고장을 원재판을 한 법원인 원심법원에 제출하여야 한다. 이는 항고심법원에 직접 제출하는 것이 아니라 원심법원을 경유하도록 함으로써 원심법원이 스스로 자신의 재판을 검토하고 오판을 교정할 기회를 부여하기 위함이다. 항고장에는 당사자와 법정대리인, 항고의 대상이 되는 원재판의 표시, 그 재판에 대한 항고의 취지를 기재하여야 한다. 민사소송법은 항소의 경우와 달리 항고 이유의 기재를 강제하지 않는 것이 원칙이나, 실무상 신속한 심리를 위해 항고 이유를 함께 적거나 별도의 항고이유서를 제출하는 것이 일반적이다. 다만, 민사집행법상 즉시항고의 경우에는 항고장에 항고 이유를 적지 아니한 때에는 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하여야 하며, 이를 위반할 경우 항고가 각하될 수 있음에 유의해야 한다. 항고장의 제출은 재판의 고지를 받은 날로부터 가능하며, 재판의 고지 전이라도 재판이 성립한 이상 항고를 제기할 수 있다는 것이 통설의 입장이다.

2. 항고기간

- 항고의 제기 기간은 항고의 종류에 따라 차이가 있다. 보통항고의 경우에는 법률상 특별한 기간의 제한이 없으므로 원재판이 취소됨으로써 얻을 수 있는 이익이 존속하는 한 언제든지 제기할 수 있다. 반면, 즉시항고는 재판이 고지된 날부터 1주 이내에 제기하여야 하는 불변기간의 제한을 받는다. 이 기간은 당사자가 재판의 고지를 받은 날부터 기산하며, 기간의 말일이 공휴일에 해당할 경우 그 다음 날까지로 연장된다. 즉시항고 기간은 불변기간이므로 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 기간을 준수하지 못한 경우에는 소송행위의 추후 보완이 허용될 수 있다. 그러나 기간을 도과하여 제기된 즉시항고는 부적법한 것으로서 각하의 대상이 된다. 재항고 역시 즉시항고에 관한 규정이 준용되므로 원심판결의 고지를 받은 날로부터 1주 이내에 제기하여야 한다.

II. 항고의 효력

1. 확정차단력과 이심력

- 항고가 적법하게 제기되면 원재판의 확정이 차단되는 확정차단력이 발생한다. 이는 상소 공통의 효력으로서 재판이 상급심의 심판 대상이 됨을 의미한다. 또한 항고장의 제출과 동시에 당해 사건은 원심법원의 수권에서 벗어나 항고심법원으로 옮겨지는 이심력이 발생한다. 다만, 항고의 경우 원심법원이 항고가 이유 있다고 인정하여 스스로 재판을 경정할 수 있는 심사수권이 인정되므로, 실제적인 사건의 기록 송부는 원심법원의 경정 절차가 종료된 이후에 이루어진다.

2. 집행정지의 효력

- 보통항고는 제기하더라도 원재판의 집행을 정지시키는 효력이 당연히 발생하지 않는다. 따라서 재판의 집행을 정지시키기 위해서는 항고법원이나 원심법원으로부터 별도의 집행정지 결정을 받아야 한다. 이와 대조적으로 즉시항고는 법률에 특별한 규정이 없는 한 집행을 정지시키는 효력을 가진다. 즉시항고가 제기되면 원재판에 기한 후속 절차의 진행이 법률상 당연히 멈추게 된다. 이는 즉시항고의 대상이 되는 재판이 확정되어야만 효력이 발생하는 경우가 많기 때문이다. 다만, 집행절차의 지연을 방지하기 위해 민사집행법 등 특별법에서는 즉시항고의 경우에도 집행정지 효력을 부정하고 별도의 집행정지 명령을 받도록 규정하는 경우가 다수 존재하므로 개별 법령의 검토가 필요하다.

III. 항고의 심판

1. 원심법원의 처리와 경정결정

- 항고장이 제출되면 원심법원은 먼저 항고의 적법 여부를 심사한다. 항고가 부적법하고 그 흠결을 보정할 수 없는 경우에는 결정으로 항고를 각하한다. 항고가 적법하다고 판단될 경우 원심법원은 항고가 이유 있는지 여부를 실질적으로 검토한다. 이때 원심법원이 항고가 이유 있다고 인정하는 때에는 그 재판을 스스로 경정하여야 한다. 이를 항고의 전심절차 또는 자조적 교정이라 한다. 이는 결정이나 명령이 판결에 비해 절차적 엄격성이 낮으므로 신속하게 오류를 바로잡기 위한 장치이다. 만약 원심법원이 재판을 경정하지 아니할 때에는 항고장 접수일부터 2주 이내에 항고기록을 항고법원에 송부하여야 한다.

2. 항고심의 심리와 결정

- 항고심의 심리는 원칙적으로 서면심리에 의한다. 판결 절차와 달리 반드시 변론을 열어야 하는 것은 아니며, 필요한 경우에 한하여 변론을 열거나 당사자 및 이해관계인을 심문할 수 있다. 항고심은 항고인의 불복 신청 범위 내에서 원재판의 당부를 심사하며, 새로운 증거의 제출이나 사실상의 주장이 허용되는 속심적 성격을 가진다. 심리 결과 항고가 부적법하거나 이유 없다고 인정될 때에는 결정으로 항고를 각하하거나 기각한다. 반대로 항고가 이유 있다고 인정될 때에는 원재판을 취소하고 항고심법원이 직접 재판하거나, 사건을 원심법원에 환송 또는 이송한다. 항고심의 결정은 당사자에게 고지함으로써 효력이 발생하며, 이에 대해 불복이 있는 경우 요건에 따라 재항고를 제기할 수 있다.

IV. 결론

- 항고의 절차는 원심법원을 경유하는 제기 방식과 원심법원 스스로의 경정 권한을 핵심으로 한다. 이는 판결 절차에 비하여 신속성과 간이성을 강조하는 결정·명령의 특성을 반영한 것이다. 즉시항고와 보통항고의 기간 차이, 집행정지 효력의 유무 등은 실무상 권리 구제의 성패를 가르는 중요한 요소가 된다. 특히 원심법원의 경정 제도는 불필요한 상급심의 업무 부담을 줄이고 당사자에게 빠른 시정을 제공한다는 점에서 효율적인 사법 운영을 가능케 한다. 항고인은 각 재판의 성질에 따른 정확한 불복 기간과 방식을 준수하여야 하며, 법원은 형식적 요건뿐만 아니라 실질적 사유를 면밀히 검토하여 재판의 정당성을 확보하여야 한다. 이러한 체계적 절차 운영을 통해 민사소송법은 소송 경제와 당사자의 절차적 기본권 보호라는 양대 목표를 조화롭게 달성하게 된다.